

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5069/2562

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาง ณ กับพวก

นาง ก. กับพวก

โจทก์

โจทก์ร่วม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4), มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 212, มาตรา 225

พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 26, มาตรา 43

สิทธินัดดีอาญามาฟ้องยอมระงับไปเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4) นั้น นอกจากจำเลยจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวและศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้ว คดีต้องมีประเด็นข้อกล่าวหาในมูลเหตุอย่างเดียวกันด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลไม่ให้ถูกดำเนินคดีถึงสองครั้งในการกระทำความผิดครั้งเดียว คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามโดยอ้างว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันหลอกลวงโจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 2 และผู้เสียหายที่ 4 ให้ซื้อและฉีดสารที่อ้างว่าเป็นสเตมเซลล์ โปรตีนและวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายโดยสารดังกล่าวไม่ใช่สเตมเซลล์และไม่ได้มีสรรพคุณตามที่จำเลยทั้งสามกล่าวอ้างแต่ข้อเท็จจริงในคดีก่อนเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 หลอกลวงโจทก์ร่วมที่ 1 โดยชักชวนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจสเตมเซลล์แต่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้จริงตามที่กล่าวอ้าง ประเด็นข้อกล่าวหาของแต่ละคดีจึงต่างกันและเป็นการกระทำต่างกรรมกัน แม้จะเป็นการฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในข้อหาฉ้อโกงเหมือนกันก็ตาม

แต่เมื่อประเด็นข้อกล่าวหาในคดีนี้เป็นคนละมูลเหตุกับประเด็นข้อกล่าวหาในคดีก่อน ฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับฟ้องคดีก่อน

ในการขายสารที่อ้างว่าเป็นสเตมเซลล์ โปรตีนและวิตามินซีนั้น จำเลยที่ 1 จะบริการฉีดยาตั้งกล่าวให้ภายหลังการขาย โดยจะติดตามไปฉีดให้แก่ลูกค้าที่สถานที่ที่ลูกค้าสะดวกในลักษณะเป็นการบริการหลังการขาย อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการขาย จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ขายสารดังกล่าว ย่อมต้องทราบทางปฏิบัติว่าจะต้องมีบริการฉีดยาตั้งกล่าวเข้าสู่ร่างกายลูกค้าด้วยเสมอ พฤติการณ์ที่มีเพียงจำเลยที่ 1 เป็นผู้ฉีดยานั้นจึงถือเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ โดยจำเลยทั้งสามมีเจตนาร่วมกันในการฉีดยาตั้งกล่าวให้แก่ลูกค้า เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งมีเจตนาร่วมกันจึงต้องรับผลแห่งการกระทำของจำเลยที่ 1 ด้วย จึงมีความผิดฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือหลายกรรมต่างกันนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 การที่จำเลยทั้งสามหลอกลวงผู้เสียหายว่าสารที่ตนนำมาขายให้แก่ผู้เสียหายคือสเตมเซลล์ที่แท้จริง ก็เพื่อประสงค์จะขายสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายเป็นสำคัญ การหลอกลวงกับการขายจึงเกี่ยวเนื่องกันไปเป็นเจตนาเดียว ความผิดฐานฉ้อโกง พยายามฉ้อโกง ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และขายยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจึงเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่การหลอกลวงขายสเตมเซลล์ให้แก่ผู้เสียหายนั้น มีเจตนามุ่งประสงค์ต่อผู้เสียหายแต่ละรายแตกต่างกันไป ทั้งยังต่างวัน เวลา และสถานที่ จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

ความผิดฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนั้น กฎหมายมุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน ในทุก ๆ ครั้งที่ประชาชนได้รับบริการดังกล่าว จำเลยที่ 1 จิตยาให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ผู้เสียหายที่ 3 และที่ 4 เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง เป็นการกระทำต่างวันเวลา จึงเป็นความผิดที่แยกต่างหากจากกัน เป็นความผิดหลายกรรมตามจำนวนครั้งที่ผิด แต่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามมาเพียงกรรมเดียวและโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ จึงไม่อาจพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งสามได้

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 26, 43 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 4, 16, 24, 57, 73 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 4, 12, 72, 101, 122, 126 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91, 341 นับโทษจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.991/2557, อ.1703/2557 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.1767/2557 ของศาลแขวงดุสิต และคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.6180/2557 ของศาลแขวงธนบุรี และนับโทษจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.991/2557 ของศาลแขวงดุสิต ริมของกลาง ให้จำเลยทั้งสามคืนเงิน 402,000 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 1 คืนเงิน 1,465,000 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 2 และคืนเงิน 70,000 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 4

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และขายยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา และฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์อ้างเป็นเหตุขอให้นับโทษต่อ ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และขายยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์อ้างเป็นเหตุขอให้นับโทษต่อ ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานางณัฐนิชา ผู้เสียหายที่ 1 และนางณัฐนันท์ ผู้เสียหายที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจทก์เฉพาะในความผิดฐานฉ้อโกง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 341 ประกอบมาตรา 80 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 26, 43 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 4, 12, 72 (4), 101, 122, 126 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันฉ้อโกง ร่วมกันพยายามฉ้อโกง ฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและขายยาที่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 101 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 3 ปี ฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 4 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่

ได้รับใบอนุญาต ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กระทั่งลงโทษหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 ฐาน ร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 1 ปี 6 เดือน และฐานร่วมกัน ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มี กำหนด 1 ปี 12 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 ฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับ ใบอนุญาต 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี 6 เดือน นับโทษจำคุก จำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.1767/2557 ของศาลแขวงดุสิต ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงิน 402,000 บาท แก่โจทก์ร่วมที่ 1 และคืนเงิน 1,465,000 บาท แก่โจทก์ร่วมที่ 2 ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.991/2557, อ.1703/2557 ของศาลแขวงดุสิต และโทษ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.6180/2557 ของศาลแขวงธนบุรี กับขอให้นับโทษจำ เลยที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.1703/2557 (ที่ฎก อ.991/2557) ของศาลแขวงดุสิตนั้น ไม่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวศาลมีคำพิพากษาแล้ว จึงไม่อาจนับ โทษต่อได้ ธิบของกลางให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฐานร่วมกัน จ้องโกงและฐานพยายามร่วมกันจ้องโกง และยกคำขอให้ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 คืนเงิน แก่โจทก์ร่วมทั้งสอง กับให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์และโจทก์ร่วมที่ 1 ฎีกา

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในประการแรกว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่ เห็นว่า ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) ที่ว่า สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องนั้น นอกจากจำเลยจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันและศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้ว คดีต้องมีประเด็นข้อกล่าวหาในมูลเหตุอย่างเดียวกันด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลไม่ให้ถูกดำเนินคดีถึงสองครั้งในการกระทำความผิดครั้งเดียว คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง โดยอ้างว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันหลอกลวงโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 และผู้เสียหายที่ 4 ให้ซื้อและจัดส่งที่อ้างว่าเป็นสเต็มเซลล์ โปรตีนและวิตามินซีเข้าสู่ร่างกาย โดยสารดังกล่าวไม่ใช่สเต็มเซลล์และไม่ได้มีสรรพคุณตามที่จำเลยทั้งสามกล่าวอ้าง แต่ข้อเท็จจริงในคดีก่อนหน้านี้ เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 หลอกลวงโจทก์ร่วมที่ 1 โดยชักชวนให้โจทก์ร่วมที่ 1 ร่วมลงทุนในธุรกิจสเต็มเซลล์แต่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้จริงตามที่กล่าวอ้าง ประเด็นข้อกล่าวหาของแต่ละคดีจึงต่างกันและเป็นการกระทำต่างกรรมกัน แม้จะเป็นการฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในข้อหาฉ้อโกงเหมือนกันก็ตาม เมื่อประเด็นข้อกล่าวหาในคดีนี้เป็นคนละมูลเหตุกับประเด็นข้อกล่าวหาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในคดีก่อน ฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับฟ้องในคดีก่อน โจทก์มีอำนาจฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมที่ 1 ประการต่อไปว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันฉ้อโกงโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 และร่วมกันพยายามฉ้อโกงผู้เสียหายที่ 4 ตามฟ้องโจทก์หรือไม่ และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องคืนเงินให้แก่โจทก์ร่วม

ที่ 1 และที่ 2 หรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าสารที่
ตนนำมาขายและฉีดให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 และผู้เสียหายที่ 4 ไม่ใช่สเต็ม
เซลล์ แต่กลับหลอกลวงว่าเป็นสเต็มเซลล์ และการหลอกลวงของจำเลยที่ 1 ได้ไป
ซึ่งเงินค่าสเต็มเซลล์จากโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 การกระทำของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์
ร่วมที่ 1 และที่ 2 จึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามฟ้องโจทก์แล้ว ส่วนผู้เสียหายที่ 4
เมื่อจำเลยที่ 1 ขายสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายที่ 4 โดยอ้างว่าเป็นสเต็มเซลล์ ผู้เสีย
หายที่ 4 หลงเชื่อและยินยอมให้จำเลยที่ 1 ฉีดสารดังกล่าวให้แก่ตนเอง การกระทำ
ของจำเลยที่ 1 จึงถึงขั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่ได้ความจากทางนำสืบโจทก์ว่า
ผู้เสียหายที่ 4 ยังไม่ได้ชำระเงินให้แก่จำเลยที่ 1 แต่อย่างใด การกระทำของจำเลยที่
1 จึงยังไม่เป็นความผิดสำเร็จเพราะยังไม่ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้เสียหายที่ 4 ผู้ถูก
หลอกลวง จึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามฉ้อโกงเท่านั้น

ส่วนจำเลยที่ 2 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 รู้อยู่แล้วว่าสารที่จำเลยที่ 1
นำมาขายไม่ใช่สเต็มเซลล์ แม้จำเลยที่ 2 ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพูดจาโน้มน้าว
ชักชวนให้โจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 และผู้เสียหายที่ 4 ซื้อสเต็มเซลล์จากจำเลยที่ 1
ก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้ไปรับสารดังกล่าวจากนางสาวพรวิไล ขันธพ
จำเลยที่ 1 ไปฉีดสเต็มเซลล์ คอยช่วยเหลือยกและถือกระเป๋าให้ แสดงว่าจำเลยที่ 2
อยู่ร่วมกับจำเลยที่ 1 ในเกือบทุกขั้นตอนของการซื้อขายสเต็มเซลล์ ทั้งไม่ปรากฏว่า
จำเลยที่ 2 มีหน้าที่การงานใดเป็นหลักแหล่ง แสดงว่าธุรกิจการขายสารที่อ้างว่าเป็นส
เต็มเซลล์เป็นธุรกิจหลักของครอบครัว การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการแบ่ง
หน้าที่กันทำกับจำเลยที่ 1 ถือว่าเป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 หลอกลวงโจทก์ร่วมที่
1 และที่ 2 และผู้เสียหายที่ 4 มีความผิดฐานร่วมกับจำเลยที่ 1 ฉ้อโกงโจทก์ร่วมที่ 1
และที่ 2 และร่วมกันพยายามฉ้อโกงผู้เสียหายที่ 4 ด้วย

ปัญหาว่าจำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำความผิดฐานฉ้อโกงและพยายามฉ้อโกงหรือไม่นั้น เห็นว่า การที่จำเลยที่ 3 รู้อยู่แล้วว่าสารที่จำเลยที่ 1 นำมาขายไม่ใช่สเต็มเซลล์แต่กลับพุดสนับสนุนให้โจทก์ร่วมที่ 1 เชื่อว่าเป็นสเต็มเซลล์ โดยพุดหลอกลวงโจทก์ร่วมที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 นำสารดังกล่าวมาฉีดให้บุคคลในครอบครัว ทำให้โจทก์ร่วมที่ 1 หลงเชื่อและตัดสินใจซื้อสเต็มเซลล์จากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 จึงมีส่วนร่วมในการหลอกลวงขายสารที่อ้างว่าเป็นสเต็มเซลล์ให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 ด้วย และถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 3 ร่วมหลอกลวงโจทก์ร่วมที่ 2 และผู้เสียหายที่ 4 อย่างไรก็ตาม แต่การพุดจาหว่านล้อมในทำนองว่าคนในครอบครัวก็ได้รับการฉีดสเต็มเซลล์ด้วยเมื่อสบโอกาส ไม่ได้เลือกที่จะหลอกลวงผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ พฤติการณ์เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ ถือว่าร่วมกับจำเลยที่ 1 หลอกลวงโจทก์ร่วมที่ 2 และผู้เสียหายที่ 4 ด้วยเช่นเดียวกัน การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 และร่วมกันพยายามฉ้อโกงผู้เสียหายที่ 4 และเมื่อจำเลยทั้งสามร่วมกระทำความผิดฐานฉ้อโกงโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 เป็นเหตุให้โจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ได้รับความเสียหาย จำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมกันชดเชยเงินคืนให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสามฐานร่วมกันฉ้อโกงและพยายามฉ้อโกงนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาของโจทก์และโจทก์ร่วมที่ 1 พังขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประการต่อไปว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและขายยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาหรือไม่ ทางนำสืบโจทก์รับฟังได้ว่า สารที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นสเต็มเซลล์ถือเป็น "ยา" ตามนิยามในมาตรา 4 (4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีจึงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาด้วย ส่วนสารที่จำเลยทั้งสามขายโดยอ้างว่าเป็นโปรตีนนั้น ไม่ปรากฏว่ามีการนำไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นยาแผนปัจจุบัน

และได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้หรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่
จำเลยทั้งสาม แต่สารที่จำเลยทั้งสามอ้างว่าเป็นวิตามินซีหรือไวตามินซีสำหรับฉีดนั้น
ตามรายงานผลการวิเคราะห์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าตรวจพบไวตามินซี ซึ่งไวตามินซีสำหรับฉีดจัด
เป็นยาแผนปัจจุบันประเภทยาอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยา
อันตราย ข้อ 3 (66) จำเลยทั้งสามไม่ได้โต้แย้งว่าเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างไร
แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 กลับฎีกาว่า วิตามินซีไม่ใช่ยาอันตราย หากจะลงโทษจำเลย
ทั้งสามก็ลงโทษได้เฉพาะฐานขายยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเท่านั้น เป็นการ
ยอมรับว่าวิตามินซีที่จำเลยทั้งสามนำมาขายนั้น เป็นยาแผนปัจจุบันและเป็นยาที่มีได้
ขึ้นทะเบียนตำรับยา ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันขายยาแผน
ปัจจุบันและยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา เมื่อจำเลยทั้งสามไม่มีใบอนุญาตให้ขายยา
ดังกล่าว จำเลยทั้งสามจึงมีความผิดฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบ
อนุญาตและขายยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามฟ้องโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องจำเลยที่ 3 มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 2 ประการต่อไปว่า
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า มีเพียง
จำเลยที่ 1 เท่านั้นที่ฉินดยาให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ผู้เสียหายที่ 3 และที่ 4 โดย
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้เป็นผู้ฉินดยาให้แก่บุคคลดังกล่าวด้วยตนเองก็ตาม แต่ใน
การขายสารที่อ้างว่าเป็นสเตมเซลล์ โปรตีนและวิตามินซีนั้น จำเลยที่ 1 จะบริการฉินด
สารดังกล่าวให้ภายหลังการขาย โดยจะติดตามไปฉินดให้แก่ลูกค้าที่สถานที่ที่ลูกค้า
สะดวกในลักษณะเป็นการบริการหลังการขาย อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการขาย
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ขายสารที่อ้างว่าเป็นสเตมเซลล์ โปรตีนและ
วิตามินซีดังกล่าว ย่อมต้องทราบทางปฏิบัติว่าจะต้องมีบริการฉินดสารดังกล่าวเข้าสู่

ร่างกายลูกค้าด้วยเสมอ พฤติการณ์ที่มีเพียงจำเลยที่ 1 เป็นผู้ฉ้อฉลนั้นจึงถือเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ โดยจำเลยทั้งสามมีเจตนาร่วมกันในการฉ้อฉลดังกล่าวให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ผู้เสียหายที่ 3 และที่ 4 เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งมีเจตนาร่วมกันจึงต้องรับผลแห่งการกระทำของจำเลยที่ 1 ด้วย จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงมีความผิดฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามฟ้อง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อไปว่า การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ เห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือหลายกรรมต่างกันนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 การที่จำเลยทั้งสามหลอกลวงผู้เสียหายว่าสารที่ตนนำมาขายให้แก่ผู้เสียหายคือสเตมเซลล์ที่แท้จริง ก็เพื่อประสงค์จะขายสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายเป็นสำคัญ การหลอกลวงกับการขายจึงเกี่ยวเนื่องกันไปเป็นเจตนาเดียว ความผิดฐานฉ้อโกง พยายามฉ้อโกง ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และขายยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจึงเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่การหลอกลวงขายสเตมเซลล์ให้แก่ผู้เสียหายนั้น มีเจตนามุ่งประสงค์ต่อผู้เสียหายแต่ละรายแตกต่างกันไป ทั้งยังต่างวัน เวลา และสถานที่ จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ซึ่งในข้อนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยทั้งสามมาเพียงกรรมเดียว และโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น แสดงว่าโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะให้ลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานดังกล่าวเป็นหลายกรรมตามฟ้องโจทก์อีกต่อไป จึงเห็นสมควรลงโทษจำเลยทั้งสามตามที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ส่วนความผิดฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนั้น กฎหมายมุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่

ได้มาตรฐาน ในทุก ๆ ครั้งที่ประชาชนได้รับบริการดังกล่าว จำเลยที่ 1 ฉีดยาให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ผู้เสียหายที่ 3 และที่ 4 เสร็จสิ้นในแต่ละครั้งเป็นการกระทำต่างวันเวลา จึงเป็นความผิดที่แยกต่างหากจากกัน เป็นความผิดหลายกรรมตามจำนวนครั้งที่ฉีด ซึ่งในความผิดฐานนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามมาเพียงกรรมเดียวและโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ ดังนั้นจึงไม่อาจพิพากษาเพิ่มเติมโทษให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยทั้งสามได้เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาลักษณะแห่งการกระทำของจำเลยทั้งสามแล้ว ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษและกำหนดโทษจำเลยทั้งสามมานั้นเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีนี้แล้ว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประการสุดท้ายว่า มีเหตุสมควรรอกการลงโทษหรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยทั้งสามนำสารที่อ้างว่าเป็นสเตมเซลล์โปรตีนและวิตามินซีชนิดฉีด มาหลอกลวงขายและฉีดเข้าสู่ร่างกายของโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ผู้เสียหายที่ 3 และที่ 4 โดยไม่ได้รับใบอนุญาตก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยทั้งสามไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ผู้เสียหายที่ 3 และที่ 4 แต่อย่างใด มีเพียงความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น และยังได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 และผู้เสียหายที่ 4 ในทำนองว่าหลังจากฉีดสารดังกล่าวแล้วมีอาการกระตุ้มกระชวย ดูสาวและสวยกว่าเดิม รวมถึงรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษในของกลาง ก็ปรากฏว่าไม่พบสารพิษในสารที่จำเลยที่ 1 ใช้นำฉีดให้แก่ผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงยังไม่ถึงกับเป็นภัยร้ายแรง การนำตัวจำเลยทั้งสามไปจำคุกกระยะสั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เสียหายและสังคมส่วนรวม เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 เคยต้องคำพิพากษาถึงจำคุกมาก่อน และแม้จำเลยที่ 1 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ในคดีหมายเลขดำที่ อ.307/2557 หมายเลขแดงที่ อ.1767/2557 และคดีหมายเลขดำที่ อ.1703/2557 หมายเลขแดงที่ อ.1337/2558 ของศาลแขวงดุสิต ให้ลงโทษจำคุก 1 เดือน และ 5 เดือน ตามลำดับ และในคดีหมายเลขดำที่

อ.6180/2557 หมายเลขแดงที่ อ.6007/2558 ของศาลแขวงธนบุรี ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน ซึ่งเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (ที่แก้ไขใหม่) เห็นสมควรให้โอกาส จำเลยทั้งสามได้กลับตนเป็นพลเมืองดี จึงเห็นสมควรรอกการลงโทษไว้ระยะหนึ่ง แต่เพื่อให้จำเลยทั้งสามเช็ดหลาบ เห็นสมควรให้มีโทษปรับอีกสถานหนึ่งด้วย

อนึ่ง ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 มาตรา 4 ให้ยกเลิกอัตราโทษใน มาตรา 341 และให้ใช้อัตราโทษใหม่แทน ปรากฏว่าโทษจำคุกตามกฎหมายเดิมและ กฎหมายที่แก้ไขใหม่มีระวางโทษจำคุกเท่ากัน ส่วนโทษปรับตามกฎหมายที่แก้ไข ใหม่มีระวางโทษปรับสูงกว่าโทษปรับตามกฎหมายเดิม ต้องถือว่ากฎหมายที่แก้ไข ใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยทั้งสาม จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะ กระทำความผิดบังคับแก่จำเลยทั้งสาม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 (เดิม), 341 (เดิม) ประกอบมาตรา 80 อีกบทหนึ่ง ลงโทษฐานร่วมกันขายยา แผลปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต วางโทษปรับจำเลยทั้งสามคนละ 5,000 บาท อีก สถานหนึ่ง และความผิดฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต วางโทษปรับจำเลยทั้งสามคนละ 5,000 บาท อีกสถานหนึ่ง รวมปรับจำเลยทั้งสาม คนละ 10,000 บาท จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานร่วมกันขายยาแผลปัจจุบันโดย ไม่ได้รับใบอนุญาตและฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพฐานร่วมกันขายยาแผลปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบ อนุญาต ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลยที่ 1 ฐานร่วมกันขายยาแผล ปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 2,500 บาท ฐานร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้รับใบอนุญาต 2,500 บาท รวมปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท คงปรับ

จำเลยที่ 2 ฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 2,500 บาท รวมปรับจำเลยที่ 2 เป็นเงิน 7,500 บาท โทษจำคุก จำเลยทั้งสามให้รอกการลงโทษไว้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยทั้งสามฟัง โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 6 ครั้ง ให้ทำกิจกรรมบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร 24 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (ที่แก้ไขใหม่) หากต้องกักขังแทนค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และเนื่องจากศาลฎีกามีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษจึงไม่อาจนับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีก่อนได้ ให้ยกคำขอในส่วนนี้ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงิน 402,000 บาท แก่โจทก์ร่วมที่ 1 และคืนเงิน 1,465,000 บาท แก่โจทก์ร่วมที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสรี เพศประเสริฐ-พิรศักดิ์ ไวกาสี-เรวัตร สกุลคล้าย)

ศาลอาญา - นายอาทิตย์ พนาจันทร์

ศาลอุทธรณ์ - นายณัฐพงศ์ ฐาปนาเนติพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอุทธรณ์ 988/2559

ต้น

หมายเหตุ